

1501629-10.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... voltada à prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06).

Para isso, eles conseguiram armas de fogo potentes, rádios e telefones para comunicação dentro da organização criminosa, balança para a pesagem das drogas, e material para contabilidade da movimentação financeira do tráfico. Além disso, eles mantinham a proteção armada em local onde era a feita a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501629-10.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501629-10.2022.8.26.0536 Controle: 357/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2119040/2022 - 01º D.P. SANTOS, 24694033 - 01º D.P. SANTOS, 2119040 - 01º D.P. SANTOS, 2119040/2022 - 1º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE MATIAS CESAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

MARCOS VINICIOS DOS SANTOS VIANA e PAULO HENRIQUE MATIAS CESAR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, ambos com observância do artigo 40, inciso IV, da mesma lei, e no artigo 16, §2º da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 15 horas, Rua Santa Mercedes, 263, CASA - Morro de São Bento, em Santos, traziam consigo e guardavam as seguintes drogas:

1) 377 porções de cocaína (peso aproximado de 484 gramas).

2) 504 porções da erva Cannabis sativa L -maconha (peso aproximado de 1,49 quilograma).

3) 175 porções de Crack (peso aproximado de 117 gramas).

Tais substâncias são drogas capazes de causar dependência física e psíquica. Segundo conta da denúncia, os denunciados pretendiam vender tudo no comércio clandestino. Eles agiam sem qualquer tipo de autorização. Os acusados praticaram o crime com emprego de armas de fogo de grande potência, de modo a realizar processo de intimidação difusa e coletiva. Consta, na denúncia, também, que, desde data não determinada e até o dia 02 de maio de 2022, em Santos, os acusados se associaram a organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). Para isso, eles conseguiram armas de fogo potentes, rádios e telefones para comunicação dentro da organização criminosa, balança para a pesagem das drogas, e material para contabilidade da movimentação financeira do tráfico. Além disso, eles mantinham a proteção armada em local onde era feita a venda de drogas no varejo. Consta, por fim, na denúncia, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados possuíam e portavam as seguintes armas de fogo de uso proibido. Elas estavam municiadas e prontas para o emprego imediato.

1. Fuzil sem marca, calibre 556, carregado com 37 munições. Essa arma não tinha seu número de identificação, que foi suprimido deliberadamente
2. Pistola Glock, calibre 9 mm, número BDLF777, carregada com 19 munições.

Os acusados foram presos em flagrante delito (fls. 01 e 23). O auto de exibição e apreensão, bem como o auto de constatação preliminar de substância entorpecente encontram-se acostados às fls. 12/13 e 16/17, respectivamente.

As folhas de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal dos acusados encontram-se acostadas às fls. 26/29.

Em audiência de custódia realizada no dia 03 de maio de 2022, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva (fls. 30/32).

Os mandados de prisão foram expedidos às fls. 39/42, sendo devidamente cumpridos às fls. 66/69.

O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 46.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação dos acusados para oferecimento de defesa prévia (fls. 54/55).

Os acusados foram devidamente notificados às fls. 72/77, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 119.

O laudo pericial dos objetos apreendidos encontra-se encartado às fls. 79/92.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 99/101, atestando resultado positivo para as substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC).

Os laudos periciais das armas de fogo e das munições apreendidas encontram-se encartados às fls. 102/118.

Por r. decisão exarada às fls. 122/123, a denúncia foi recebida.

O laudo pericial realizado no celular apreendido encontra-se encartado às fls. 168/182.

Os acusados foram pessoalmente citados às fls. 186/189.

Por r. decisão proferida às fls. 212/214, nos termos do Comunicado C.G. nº 78/2020, a prisão preventiva dos acusados foi revista e mantida.

Em audiência virtual realizada no dia 01 de setembro de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo os réus interrogados. (fls. 227/228)

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada. (fls. 235/240)

A ilustre defesa dos réus manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a absolvição dos réus, em relação ao delito descrito no art. 35, da Lei de Drogas, por ausência de dolo dos acusados se associarem. Requereu a absolvição dos réus, em relação ao delito descrito no art. 16, § 2º, da Lei 10.826/06, alegando o princípio da especialidade. Pleiteou o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando com causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Requereu a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, a concessão do regime o regime semiaberto e o direito dos acusados recorrerem em liberdade, expedindo-se os competentes alvarás de soltura para os réus. (fls. 246/260)
É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01 e 23, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelo auto de constatação preliminar de fls. 16/17, pelo relatório final de fls. 46, pelo laudo pericial dos objetos apreendidos de fls. 79/92, pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 99/101, atestando resultado positivo para as substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), bem pelo laudo pericial das armas de fogo apreendidas de fls. 102/118.

Por sua vez, a autoria dos delitos restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Marcos confessou a prática do delito, alegando que encontrava-se no terceiro dia de atividades, em troca de R\$ 150,00 (centro e cinquenta reais). Afirmou que encontrava-se com um fuzil na data dos fatos e, durante a abordagem policial, lançou a mochila preta, que portava 03 potes de lança perfumes para venda, no mato. Informou ter encontrado o corréu Paulo antes da abordagem policial e os dois fugiram juntos para residência que se abrigaram. Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Paulo confessou a prática do delito, alegando que encontra-se desempregado e aceitou uma proposta financeira para que "segurasse" uma sacola e uma pistola. Dois dias depois, na data dos fatos, ao perceber que os policiais realizavam operação no morro, o interrogando correu, adentrando na residência de um morador e escondendo-se na cozinha. As mochilas e a pistola ficaram no mato no fundo da residência. Narrou que os policiais realizaram sua prisão dentro da residência e localizaram os objetos no mato. Informou que o fuzil não estava em sua posse, mas a pistola sim. Alegou ter recebido R\$ 200,00 (duzentos reais) para a prática do delito e não possuir antecedentes criminais. Por fim, afirmou ter encontrado o acusado Marcos apenas dentro da residência.

O policial militar Kleber Marinho Valões, testemunha de acusação ouvida em Juízo, relatou que estavam em uma operação policial conjunta, com objetivo de coibir ações ilícitas pelo morro e identificar indivíduos que estariam efetuando disparos aos policiais que realizam o policiamento ordinário. Narrou que, ao subirem a escadaria do Morro Santa Luzia, avistaram ao fundo dois indivíduos que tentavam se evadir das equipes policiais que desciam pelo Morro. No momento em que os acusados perceberam os policiais, retornaram seu trajeto e adentraram nas residências de moradores do local, ocultando as drogas e as armas em meio aos matos do fundo da casa. Relatou que foi possível notar que os acusados encontravam-se portando armas de fogo, sendo um fuzil e uma pistola 9mm. Informou que os acusados foram detidos na cozinha da residência, escondidos atrás de uma geladeira. As drogas, as armas e uma mochila foram localizadas pelo seu companheiro de farda Caio, juntamente com a equipe policial, em meio a mata no fundo do terreno. Foram localizados, ainda, drogas diversas como maconha, cocaína, lança perfume, além de dinheiro e anotações do tráfico. Relatou que o fuzil estava com o compartilhamento carregado com 30 munições e dentro de uma pochete havia 7 munições. Informou que as escadarias dos Morros são pontos de traficância, porém a residência em que os acusados se ocultaram não. Narrou que as armas de fogo e os entorpecentes foram localizados no mesmo contexto fático, sendo que as armas são utilizadas para fazer a segurança e coagir qualquer confronto ao ponto de tráfico. Por fim, relatou não ser possível afirmar se havia estabilidade e permanência dos acusados no tráfico de drogas, pois a rotatividade dos indivíduos é constante.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado por Caio Fernando Castanho, policial militar ouvido em Juízo, que corroborou o depoimento prestado por sua colega de farda. Acrescentou, ainda, que ficou encarregado de recolher os objetos deixados pelo acusados na mata localizada no fundo da residência. Informou que dentro das mochilas havia diversas drogas, dinheiro e cadernetas com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. O fuzil e a pistola estavam carregados com munições. Afirmou que

as armas de fogo e os entorpecentes foram encontrados no mesmo contexto fático, bem como ser costumeiro a utilização de armas de fogo para garantir a segurança do local. Por fim, informou não ser possível apurar a função de cada acusado, e não ter observado atos de mercancia, pois as drogas estavam dentro das mochilas. Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois ambos narraram com riqueza de detalhes de que maneira se desencadearam os fatos e confirmaram a apreensão das drogas conforme indicado na denúncia. Seus depoimentos foram firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo a ocorrência dos fatos de forma uníssona.

Os depoimentos dos policiais sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade". (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção juris tantum da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Ressalta-se que a i. defesa dos acusados não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais militares ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudicá-los.

O conjunto probatório é absolutamente seguro e incriminador e aponta sem sombra de dúvidas os acusados como sendo os autores do crime de tráfico de drogas descrito na inicial.

O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da grande quantidade de drogas apreendidas, seu modo de acondicionamento, diante dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias em que ocorreu a prisão dos acusados, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 99/101.

No delito de tráfico (artigo 33, "caput") e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isto porque os acusados, apesar de primários, possuíam 377 porções de cocaína (peso aproximado de 484 gramas), 504 porções da erva Cannabis sativa L -maconha (peso aproximado de 1,49 quilograma), 175 porções de Crack (peso aproximado de 117 gramas), deixando demonstrada sua ligação com organizações criminosas, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos.

Desta forma, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem evidenciar que os réus se dedicam habitualmente ao crime ou fazem parte de organização criminosa e, nesses casos, eles não terão direito à redução de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos IV da Lei de Drogas, restou devidamente demonstrada, pois o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi praticado pelos réus, os quais se encontravam armados, conforme bem confirmado pelos depoimentos prestados em Juízo.

Entretanto, no tocante ao crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, é forçoso concluir que as provas produzidas no curso do processo efetivamente precárias e insuficientes para demonstração da prática dessa modalidade criminosa. O artigo 35 do mencionado diploma legal retrata modalidade especial de associação

criminosa (artigo 288 do Código Penal). Contudo, diferentemente do mencionado delito, o crime de associação para o tráfico exige apenas duas pessoas, agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06.

Para a caracterização do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, não basta a convergência de vontades para a prática das infrações constantes nos artigos 33 e 34 da mesma lei. É necessário, também, a intenção associativa com a finalidade de cometê-las, o dolo específico.

Para o reconhecimento do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas o animus associativo há de ser devidamente provado, pois é figura integrante do tipo, indispensável para a sua caracterização.

Nesse sentido, não existem nos autos provas suficientemente robustas que indiquem a existência de associação estável e permanente entre os acusados para a prática de crimes, restando somente comprovado o delito de tráfico de entorpecentes.

No que tange ao delito de porte ilegal de armas, descrito no artigo 16, §2º da Lei nº 10.826/03, acolho a tese defensiva e aplico o princípio da consunção, uma vez que é evidente que as armas eram destinadas à proteção e ao exercício da atividade principal, ou seja, o tráfico de drogas.

O princípio da consunção se caracteriza nos casos que um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou seja, quando um fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.

No caso em tela, destaca-se a existência de causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, quando há emprego de arma de fogo e que essa hipótese abarca a utilização de armamento para garantir a segurança pessoal enquanto perdura a atividade criminosa.

Assim, com relação aos delitos de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, impõe-se a absolvição dos acusados, devendo os mesmos responderem pelo crime do art. 33 combinando com art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06.

Os acusados, em Juízo, confessaram a prática dos delitos, devendo ser aplicada a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, letra "d", do Código Penal. Assim sendo, seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, em relação ao crime do art. 33 cc art. 40 inciso IV da Lei de Drogas, impõe-se o desfecho de parcial procedência da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra MARCOS VINÍCIOS DOS SANTOS VIANA e PAULO HENRIQUE MATIAS CESAR, a fim de ABSOLVÊ-LOS das imputações contidas no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 2º, da Lei nº 10.826/03 e CONDENÁ-LOS como incurso nas penas do artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, com observância do artigo 40, incisos IV, da mesma lei.

1 - Em relação ao delito previsto no artigo 33, c.c. o artigo 40, incisos IV da Lei nº 11.343/06, praticado pelo acusado MARCOS VINÍCIOS DOS SANTOS VIANA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, diante da grande quantidade da droga apreendida, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Verifico estar presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual, atenuo a pena aplicada ao acusado em 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, perfazendo um total de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Reconheço a causa de aumento de pena prevista nos incisos IV, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento em um sexto a pena ora aplicada ao acusado, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

2 - Em relação ao delito previsto no artigo 33, c.c. o artigo 40, incisos IV da Lei nº 11.343/06, praticado pelo acusado PAULO HENRIQUE MATIAS CESAR:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, diante da grande quantidade da droga apreendida, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Verifico estar presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual, atenuo a pena aplicada ao acusado em 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, perfazendo um total de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Reconheço a causa de aumento de pena prevista nos incisos IV, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento em um sexto a pena ora aplicada ao acusado, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Torno definitivas as penas aplicadas.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, para ambos os acusados, nos termos do artigo 33 do Código Penal e em razão da hediondez do delito, conforme a Lei 11.464/07, que alterou a redação da Lei nº 8.072/90.

Os acusados foram presos em flagrante delito, permanecendo presos durante toda a instrução e, diante da presente sentença condenatória e, face à lesividade de suas condutas à sociedade, deverão aguardar presos o julgamento de eventual recurso a ser interposto.

A manutenção da prisão preventiva dos acusados justifica-se plenamente a fim de garantir-se a ordem pública e também visando assegurar-se o cumprimento da lei penal, ante a presente condenação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva decretada às fls. 30/32.

Ressalte-se que em relação à aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de detração penal na sentença condenatória, a alteração legislativa fez surgir duas interpretações principais. A primeira entende caber ao juízo do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, depois de efetuado o cálculo da pena, computar o tempo de prisão processual e, considerando a detração, determinar o regime inicial de cumprimento da pena. A segunda entendendo que somente o juízo da execução tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os requisitos legais para eventual progressão do regime. (TJ-SP HC 2107326-63-2015 – Des. Rel. J. Martins).

Neste sentido, comungo do entendimento que a detração deve ser analisada no Juízo das Execuções, a quem compete decidir, sob pena, inclusive, de supressão de instância, a presença de méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão, motivo pelo qual deixo de aplicar o instituto.

Recomendem-se os réus nas prisões em que estiverem.

Após o trânsito em julgado, anatem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA